

1500574-94.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... ainda, celulares, nos quais havia informações sobre o tráfico de drogas perpetrado, o que o próprio réu teria assumido aos policiais, já que estes afirmaram que não verificaram os aparelhos.

Destarte, a confissão do réu, em juízo, elucidou o motivo pelo qual ele empreendeu fuga ao avistar a viatura policial: JOALISSON praticava o tráfico de entorpecentes, o que assumiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500574-94.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500574-94.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOALISSON BARBOSA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

JOALISSON BARBOSA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 00h10min., na Avenida João Alvim, 1.260, Atibaia Jardim, em Atibaia, transportava - fazendo uso de veículo Ford/Ka, placas CTB6J96 - e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, 407 porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, o réu transportava 13 porções de cocaína no interior do veículo Ford/Ka, placas CTB6J96, o qual conduzia em alta velocidade. Assim, ao notar a presença de uma viatura policial que vinha no sentido contrário, passou a aumentar a velocidade, a fim de não ser abordado.

Conforme constou da exordial, os policiais deram meia volta e foram ao encalço do réu, verificando, pela placa do carro, que se tratava de veículo em relação ao qual pesavam várias informações sobre ser usado para o tráfico de drogas. Ademais, os agentes deram sinais de parada ao réu, que os ignorou e seguiu pela via em alta

velocidade. Porém, um pouco mais adiante, ao perceber que não conseguiria fugir, acabou parando o veículo e sendo abordado.

A inicial narrou que ao ser indagado sobre o motivo da fuga, JOALISSON admitiu que assim agira em razão de estar na posse de objetos ilícitos. Feita a busca pessoal, os policiais acharam consigo as 13 porções de cocaína e um celular, bem como a quantia de R\$ 272,00. Já em busca veicular, localizaram mais R\$ 300,00 em notas diversas.

A denúncia descreveu que novamente questionado, JOALISSON confessou que estava traficando drogas, informando que havia mais entorpecentes e dinheiro em sua casa. Desta forma, ante a situação de flagrante delito e os inúmeros indícios presentes no caso em tela, os policiais foram à residência do réu, onde, com a sua aquiescência, adentraram e acharam as demais porções de cocaína, além de mais dinheiro, cerca de R\$ 700,00 e três celulares que, de acordo com o réu, possuíam informações sobre a venda de drogas.

Réu preso em flagrante, sendo sua prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia (fls. 49/51).

Por força de liminar obtida em Habeas Corpus, entretanto, a prisão preventiva do réu foi substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 79/97 e 103), tendo o réu alcançado a liberdade (fls. 114/117).

A denúncia foi oferecida (fls. 74/75), o acusado foi notificado (fls. 123/124) e apresentou defesa preliminar (fls. 144/158), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 197/200).

O réu foi regularmente citado (fls. 234). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final (fls. 235/236).

Em memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 237/242).

A defesa argumentou que o réu não empreendeu fuga em momento algum, apontando que só foi abordado por ser antigo desafeto, desde os tempos de infância, do agente Atilio, que efetuava o patrulhamento naquele local. Alegou que o réu permaneceu em silêncio durante a abordagem (assim como fez em solo policial), não sendo verdadeira a narrativa dos policiais de que o réu teria confessado a prática naquele momento. Alegou, também, que os policiais chegaram à residência do réu porque o policial desafeto do réu conhecia seu endereço, tendo afirmado que o acusado, em momento algum, autorizou o ingresso no local, apontando que os agentes estouraram o cadeado e derrubaram o portão, quebrando o concreto da viga de sustentação do muro. Pontuou que o réu confessou o delito, o qual praticou em razão de sua extrema necessidade, afirmando, entretanto, nunca ter se envolvido com qualquer organização criminosa. Alegou, ainda, violação de direitos constitucionalmente assegurados, como o direito de permanecer em silêncio e o não oferecimento do direito de o réu permanecer em silêncio, a inviolabilidade de domicílio (tendo acostado fotografias do portão da residência, do cadeado e do armário da casa do réu) e a não apresentação de registros hábeis a comprovar a alegação de que o veículo que estava sob a posse do acusado contava com denúncias a respeito do envolvimento com o tráfico de drogas, fundamentando tais argumentações e requerendo, por conta das nulidades que entendeu existir, por violação às regras previstas nos incisos XI e LXIII do artigo 5º da Constituição Federal, a inadmissibilidade das provas, a restituição do automóvel à irmã do acusado e a absolvição do réu. Para o caso de condenação, postulou o reconhecimento da confissão do acusado como forma de lhe atenuar a pena, a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime aberto para cumprimento de pena, a restituição do veículo apreendido à irmã do réu, sem cobrança de taxas do pátio, gratuidade da justiça, desconsideração da pena de multa ou sua fixação no mínimo legal e direito de o réu apresentar recurso em liberdade.

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls.

01/02), no boletim de ocorrência (fls. 07/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), nas fotografias (fls. 14/19), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 22/23), no laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 184/185) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, optou por permanecer em silêncio (fls. 06).

Em juízo, o réu negou o tráfico de drogas; disse acreditar que, ao todo, tinha quatrocentas e quarenta e três porções; guardava as porções em sua casa devido a condições financeiras, pois estava passando muita dificuldade; não tinha condição financeira para ajudar seus filhos, dar alimento ou um botijão de gás; teve a oportunidade de guardar as substâncias ilícitas em sua casa e ganhar dinheiro com isso; quis ganhar dinheiro para ajudar sua família e acabou errando; dizer que estava traficando, como estão alegando, é mentira; ia ganhar de R\$ 2.000,00 a R\$ 3.000,00; conheceu um rapaz, cujo apelido era Buiú, com quem não tinha muita intimidade, que lhe disse que estava precisando de alguém para guardar; Buiú faz parte da criminalidade; só o viu poucas vezes e como essas coisas aconteceram, ele sumiu; confirmou que estava guardando a droga para um criminoso traficar, mas não chegou a ganhar dinheiro, pois era recente; o dinheiro encontrado era uma parte do valor que o rapaz havia lhe dado; todo o dinheiro foi em virtude de guardar a droga; a droga encontrada consigo era para levar e deixar em casa, mas os policiais acabaram abordando e encontrando consigo; as treze porções que estavam consigo eram para guardar; não faz uso de drogas; atualmente está trabalhando e fazendo curso; não tinha guardado essas substâncias em sua casa porque sua mulher estava lá e não sabia de nada, pois era recente, então resolveu não falar nada para sua mulher; estava indo buscar um lanche para seus filhos e foi aí que os policiais o abordaram; indagado sobre o fato de ter dito que não havia recebido nada, mas que estava com R\$ 1.200,00, respondeu que ia receber entre R\$ 2.000,00 a R\$3.000,00 e essa quantia foi a parte que o rapaz lhe deu para deixar as drogas em sua casa; trabalha registrado e está auferindo atualmente R\$ 1.670,00; estudou até o terceiro ano completo; foi processado quando era menor de idade, por mão armada, mas como adulto, nunca foi processado anteriormente; quando os policiais o pegaram nessa rua na qual disseram que deu fuga, não fugiu; se quisesse ter feito isso, teria a oportunidade de fazer, tanto de carro como andando; Atilio disse que o conhecia e que nunca tiveram atrito, mas tiveram atrito sim, quando eram crianças; brigavam muito e estudavam na escola pública; Atilio lhe jogou dentro da viatura falando que ia levá-lo para sua casa; perguntou até se sua mulher estava lá, chamou uma policial mulher para ir junto, pois se caso sua mulher estivesse lá, ela iria sofrer as consequências, mas sua mulher estava trabalhando naquele momento, pois não sabia de nada; indagado se sua mulher estava trabalhando à meia-noite, respondeu que sim, que sua mulher trabalha com lanchonete; levaram-no a força para sua casa; Atilio já o conhecia e não gostava de sua pessoa; ele falou que tinham um bom relacionamento, mas não tinham; Atilio já o perseguia fazia um tempo; foram à força para sua casa; os policiais arrombaram seu portão, pois não conseguiam abrir o cadeado; Atilio achou o restante das drogas em um único local, não da forma que ele disse; indagado sobre o motivo pelo qual o policial precisaria arrombar sua casa e vasculhar, se estava junto, respondeu que não estava junto; o policial disse isso, mas não estava junto; estava ali, porém não autorizou a entrada em sua casa. A testemunha Carlos Eduardo Franco Taveira, policial militar, disse que estava em patrulhamento, pelo bairro Alvinópolis, e no contrafluxo veio um veículo preto, que se não se engana era um Ford Ka que, quando viu a viatura, aumentou a velocidade e passou a viatura em alta velocidade; fizeram a volta e foram atrás dele; o veículo entrou na rua Joviano Alvim e continuou em alta velocidade, com a viatura indo atrás tentando dar sinal de parada; quando o veículo estava chegando próximo da avenida Atibaia, que viu que não conseguiria se evadir, parou; foi perguntado por que ele tentou se evadir da viatura, e ele disse que estava transportando objetos ilícitos; foi feita busca pessoal no indivíduo, sendo que encontraram alguns papелotes de cocaína embalados, além de uma quantidade de aproximadamente R\$ 200,00 em dinheiro; na busca veicular, foi encontrado mais dinheiro; em entrevista com ele, tentando entender a procedência, se estava entregando droga, ou o que era, ele

admitiu que estava traficando; falou com a equipe que se o liberassem, diria onde tinha mais droga; perguntaram onde tinha mais droga e ele disse que em sua casa; questionou se ele autorizaria a entrada da equipe em sua casa e ele os levou até lá, onde foi localizado mais droga, dinheiro e celulares; não mexeram nos celulares, mas perguntaram a ele e o réu admitiu que em todos haviam informações sobre tráfico de drogas; conduziram tudo para a Delegacia; às reperguntas do defensor de JOALISSON, respondeu que não havia denúncias formais contra o veículo em posse do acusado; tinham conhecimento de que o veículo poderia estar sendo usado em ocorrências com entorpecentes.

A testemunha Atilio José da Costa Junior, policial militar, disse que na noite dos fatos, estavam em patrulhamento, pelo Jardim Atibaia, quando se depararam com o carro do réu no contrafluxo; de imediato, fez o retorno, voltou, deu voz de parada para o réu, que não obedeceu de imediato, seguindo sentido Avenida Atibaia; em certo momento, o réu viu que não iria conseguir se desvencilhar da viatura e parou; foi dada voz de comando para o réu descer do veículo; em busca pessoal, encontraram invólucros de cocaína, no bolso direito da jaqueta dele, além da quantia de R\$ 272,00; indagaram ao réu sobre a finalidade da droga e sobre o dinheiro, tendo o acusado dito que fazia tráfico de drogas e que havia mais dinheiro dentro do carro; feita a busca veicular, encontraram cerca de R\$ 300,00 no veículo; em conversa com o réu, ele disse que na casa dele havia mais drogas e mais dinheiro; o réu franqueou sua entrada na casa dele e lá, o réu indicou onde havia mais dinheiro e droga, ou seja, numa gaveta embaixo da cama da filha dele e no outro cômodo, em cima do guarda-roupa; o réu foi quem mostrou onde estavam as drogas; não conhecia o réu de outras abordagens, mas era conhecido de infância; já tinham denunciado para sua pessoa, por saberem que era policial, que o réu usava o carro para prática de tráfico; às reperguntas da defesa, indagado sobre o motivo pelo qual essas denúncias não foram formalizadas, respondeu que essas denúncias foram feitas informalmente por pessoas que conhecem o réu; indagado se é considerado inimigo do réu, respondeu que não, explicando que na casa sua avó tem uma foto sua e do réu lutando capoeira, de quando eram mais novos; quando eram menores, se davam bem, nunca tiveram atrito; indagado sobre o motivo do portão da casa do réu ter sido quebrado, uma vez ter alegado que a entrada foi franqueada, respondeu que quem abriu o portão foi o réu, com a própria chave dele, sendo que na hora em que o réu foi puxar, o portão caiu; os policiais não fizeram nada.

Pois bem.

O réu, que iniciou seu interrogatório negando a acusação que o onera, acabou, em verdade, confessando a prática delitiva, ao afirmar que possuía cerca de quatrocentas e quarenta e três porções, as quais guardava por necessidades financeiras. Declarou que auferiria, com a prática, de R\$ 2.000,00 a R\$ 3.000,00, e que indivíduo cuja alcunha era "Buiú" foi quem lhe solicitou que guardasse o entorpecente.

O réu assumiu, ainda, que o dinheiro encontrado era parcela do valor que Buiú havia lhe dado.

Os agentes policiais corroboraram a confissão do réu, relatando que durante patrulhamento, o veículo do réu, que estava em contrafluxo, aumentou de velocidade ao notar a viatura.

De acordo com os agentes, após breve perseguição, em que ocorreu desobediência aos sinais de parada, ao não mais conseguir se evadir, o veículo parou e ocorreu a abordagem.

Ao indagarem ao réu o motivo da fuga, os policiais obtiveram por resposta a informação de que o acusado estava transportando objetos ilícitos.

Em busca pessoal, os agentes confirmaram que encontraram papelotes de cocaína, além de R\$ 272,00 em dinheiro. No veículo, foi encontrado mais dinheiro (cerca de R\$ 300,00) e, em entrevista com o acusado, ele assumiu que praticava o tráfico e que em sua casa havia mais entorpecentes.

Com efeito, os policiais declararam que foram até a residência do réu, onde o próprio acusado indicou onde havia mais entorpecentes, ou seja, numa gaveta embaixo da cama da filha dele e no outro cômodo, em cima do guarda-roupa. Encontraram, ainda, celulares, nos quais havia informações sobre o tráfico de drogas perpetrado,

o que o próprio réu teria assumido aos policiais, já que estes afirmaram que não verificaram os aparelhos.

Destarte, a confissão do réu, em juízo, elucidou o motivo pelo qual ele empreendeu fuga ao avistar a viatura policial: JOALISSON praticava o tráfico de entorpecentes, o que assumiu aos policiais, levando-os até sua residência, onde guardava colossal quantidade de cocaína, sendo certo que em juízo, o réu repetiu sua confissão, mesmo negando, inicialmente, a prática de tráfico.

Quanto aos agentes da Lei, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

O laudo pericial de fls. 184/185 foi apto a indicar a apreensão, pela polícia, de substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, qual seja, a cocaína.

Os argumentos defensivos para requerer nulidade do flagrante levado a efeito e das provas produzidas, visando com isso sustentar a absolvição do réu - que confessou o delito, repiso - não se sustentam.

Primeiramente, não há que se falar sobre não ter havido alerta, ao réu, sobre seu direito de permanecer em silêncio, o chamado "Aviso de Miranda".

A ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, por parte dos policiais, seria capaz tão somente de ensejar eventual nulidade relativa, sendo necessário para seu reconhecimento, comprovar real prejuízo experimentado pelo réu, coisa que não foi feita e não se observou no feito; ademais, embora o réu tenha permanecido em silêncio perante a autoridade policial, durante seu interrogatório (fls. 06), o fato é que em resposta às informações sobre sua vida pregressa, ao ser indagado se estava arrependido pela prática do crime, respondeu que sim. Além disso, ao ser indagado se sua atitude foi premeditada e, portanto, o fim alcançado estava na sua vontade, respondeu novamente que sim, a demonstrar que embora não tenha confessado o crime expressamente perante o Delegado, se arrependeu da prática que levou a efeito, ou seja, a traficância que empreendeu.

Nada impede, portanto, que tenha, de fato, confessado informalmente o delito aos policiais, conforme narraram os agentes ouvidos, sendo certo que tal prática, ou seja, a confissão informal e a permanência em silêncio perante o Delegado de Polícia, é comum, havendo que se considerar que do momento do flagrante levado a efeito até o depoimento perante a autoridade policial há um interlúdio temporal significativo, havendo tempo para o então indiciado mudar de ideia quanto a eventual confissão informal levada a efeito anteriormente.

Sobre o tema, brilhante julgado:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA.

MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja

cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R\$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região. 3. Quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada. 4. Em relação ao pedido de desclassificação da conduta, o tema não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental. 5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 6. Habeas corpus não conhecido" (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (destaquei).

Não é demais rememorar que o réu, em solo policial fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o que não o impediu de informar seu nome completo, endereço, filiação e outros detalhes a respeito de sua pessoa, bem como de sua esposa (de quem até o telefone informou), não tendo sofrido (nem demonstrado) qualquer prejuízo ao fazê-lo.

O fato é que o réu confessou o delito aos policiais, da forma como estes informaram em seus depoimentos policiais e judiciais, sendo certo que tal confissão ensejou a ida dos agentes até a residência do acusado, onde mais entorpecentes, dinheiro e celulares foram encontrados. Além disto, a confissão informal foi corroborada pela confissão judicial, como afirmado pelos depoimentos dos já mencionados agentes, havendo prova suficiente, portanto, quanto à materialidade e autoria do delito, apta a ensejar a condenação do acusado.

Por fim, e mais importante, o fato de o réu ter assumido aos policiais que possuía drogas em sua residência não foi questão utilizada como supedâneo para o decreto condenatório: sua própria confissão em juízo, corroborada pela narrativa dos policiais acerca das diligências que ensejaram a prisão em flagrante do acusado é que sustentam a sentença que ora se amolda.

Assim, eventual ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, por parte dos policiais, não gerou qualquer nulidade, nem muito menos prejuízo, seja no flagrante levado a efeito, seja na prova formada a partir dele. Não há que se falar, ainda, sobre violação de domicílio.

As fotografias acostadas pela Defesa não comprovam ter havido qualquer violação do domicílio do réu. Há imagem de rachadura num muro, aparentemente residencial, de um cadeado aberto (sendo que o réu, em seu interrogatório, afirmou que os policiais arrombaram o portão por não conseguirem abrir o cadeado, não havendo segurança, sequer, portanto, de que o cadeado da foto se trata exatamente o cadeado da residência do réu) e de um guarda-roupas com a porta caída, não havendo como assegurar que referida porta tenha caído justamente no momento da ação policial. Ou seja, nada provam as fotos juntadas.

A narrativa do réu de que era perseguido por um dos policiais, seu desafeto de infância, não restou corroborada por qualquer prova formada. Em verdade, o próprio

policial assumiu que conhecia o réu, com quem, inclusive, tirou fotografia na infância, não tendo sido demonstrada a existência de qualquer entreeiro prévio entre ambos. Outrossim, repito, não houve incriminação falsa do réu, mas ele próprio confessou que traficava.

A realidade apurada é que o réu, flagrado em posse de entorpecentes, afirmou aos agentes policiais que possuía mais drogas e dinheiro de origem espúria em sua residência. Com base em tal informação, os agentes foram com o réu até a casa deste e lá, de fato, encontraram os entorpecentes e o dinheiro, a partir de indicação do próprio réu.

Não obstante, recorrentes são as decisões perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de que a situação de flagrância autoriza a entrada dos agentes independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão ou autorização de moradores, já que a ação estaria em conformidade com o quanto disposto no artigo 5º, inciso IX da Constituição Federal.

A saber:

"REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da prova por violação de domicílio. Inocorrência. Situação de flagrância que autoriza o ingresso dos policiais militares independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão ou autorização do morador. Indeferimento do pedido" (TJ-SP – RVCR: 0024328-96.2020.8.26.0000; Relator: Leme Garcia; Data de Julgamento: 01/06/2021; 8º Grupo de Direito Criminal; Data de Publicação: 01/06/2021).

E ainda:

"'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio – Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente – Não acolhimento – Ausência de constrangimento ilegal – Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" – Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" – Crime permanente – Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) – Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente – Precedentes – Ordem denegada (TJ-SP – HC 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator: Juscelino Batista; Data de Julgamento: 08/04/2021; 8ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 08/04/2021).

Por fim, a alegação quanto à ausência de provas a respeito de denúncias acerca do uso do veículo, por parte do réu, para o tráfico de entorpecentes não enseja qualquer nulidade, posto que, conforme já fundamentado, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao réu pelo fato de o agente policial ouvido em audiência ter mencionado tais denúncias.

A abordagem inicial, de acordo com ambos os policiais ouvidos, ocorreu por conta da postura do réu, que ao notar a viatura, empreendeu fuga com o veículo. Irrelevante para o deslinde do feito não haver juntadas aos autos de eventuais denúncias acerca do veículo utilizado pelo réu para prática reiterada do tráfico. O fato é que, naquele momento, o réu estava utilizando o veículo para a traficância que empreendia, já que assumiu, durante seu interrogatório, que guardaria as porções que transportava no automóvel.

As demais argumentações defensivas não foram capazes de infirmar a acusação que recai sobre o réu, não restando dúvidas, portanto, a respeito da prática, por parte do acusado, do delito pelo qual foi denunciado.

Destarte, a confissão do réu foi corroborada plenamente pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo certo que o arcabouço probatório respalda, fundamenta e alicerça plenamente o decreto condenatório que ora se amolda, pelo delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

A condenação, nos termos pelos quais o réu foi denunciado, é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a

personalidade e a conduta social do agente.

O réu é tecnicamente primário. Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade. Quanto aos motivos do crime, nada a ensejar a modificação de pena. Quanto à natureza e quantidade do produto, foram apreendidas 407 porções de cocaína, quantidade colossal, que será levada em consideração na última fase de dosimetria de pena. Assim, com base no exposto nesta primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Quanto ao valor da diária, considerando que o réu disse auferir cerca de R\$ 1.670,00 trabalhando registrado, bem como que o valor do dia multa deve corresponder a 1/30 do valor percebido pelo acusado, fixo o dia-multa em R\$ 55,00. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes. A atenuante referente à confissão incide, mas não surte efeitos práticos, considerando-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não podendo ser atenuada a patamar inferior nesta fase de dosimetria, em homenagem à Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento a serem consideradas.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Embora primário, o acusado confessou envolvimento com o universo da traficância, tendo assumido que aceitou guardar entorpecentes para terceira pessoa envolvida com a criminalidade, demonstrando, assim, seu envolvimento com o tráfico de drogas e o crime em geral, o que por si só impede objetivamente a concessão do benefício. Não bastasse, a enorme quantidade de entorpecente apreendida demonstra que havia dedicação, por parte do réu, à atividade ilícita em questão. Considerado o envolvimento do réu com a traficância, bem como a colossal quantidade de drogas que mantinha em depósito, entendo incabível o reconhecimento de qualquer causa de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva do acusado em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização – sobre o óbvio, diga-se –, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática – a tão altos custos – permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensejar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto e, principalmente, porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminoso ligada

ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será

detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno JOALISSON BARBOSA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 dias-multa, diária fixada em R\$ 55,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal.

O réu respondeu ao processo em liberdade e, não havendo alteração fática apta a ensejar mudança de sua atual situação, poderá oferecer recurso, se assim desejar, em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

Decreto a perda, em favor do FUNAD, da quantia apreendida. Transitada em julgado, oficie-se para levantamento.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade da Justiça.

Por fim, considerando-se que a prova formada acerca do uso do veículo para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes não se mostrou segura o suficiente, uma vez que apesar de os policiais ouvidos terem informado sobre a existência de

denúncias informais de que o réu usaria o automóvel para a prática delitiva em comento, o fato é que não se formou prova suficiente a atestar o uso reiterado do automóvel para a traficância.

Quanto ao pagamento de taxas, a previsão do artigo 271, § 1º do CTB, está limitada aos casos em que a apreensão do veículo se der por infração às regras de trânsito, não quando determinada pela autoridade policial em investigação criminal. Neste caso, quando apreendido em virtude de investigação criminal, o procedimento de restituição do veículo ao proprietário obedece ao disposto nos artigos 118 a 124-A do Código de Processo Penal, onde inexistente a previsão de pagamento de qualquer valor. Assim, tratando-se de veículo apreendido em investigação criminal, que não guarda relação com infrações de trânsito, comprovada a propriedade do veículo, possível a sua liberação com isenção do pagamento de encargos de guincho e estadia. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA Liberação de veículo com isenção do pagamento de taxa administrativa de estadia ADMISSIBILIDADE A liberação de veículo automotor apreendido para fins de investigação criminal não pode ficar condicionada ao pagamento de eventuais custas administrativas. Inteligência do artigo 6º, da Lei 6.575/78. Segurança concedida. (TJSP MS 2154680-45.2019.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, publicado em 28/08/2019, Relator Paulo Rossi). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à análise do pedido de isenção do pagamento de taxas e despesas reconhecida. Lei nº 6.578/78, revogada pela Lei nº 13.460/15. Matéria atualmente tratada no Código de Trânsito Brasileiro (artigos 270, 271 e 328). Artigo 328, § 14, do CTB, que ressalva a hipótese dos veículos recolhidos a depósito por ordem judicial ou à disposição de autoridade policial. Proprietário que não deu causa à apreensão do veículo. Embargos acolhidos para sanar omissão, determinando que a entrega do veículo não seja condicionada ao pagamento de taxas e despesas.” (Embargos de declaração nº 2067417-77.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des. LEME GARICA; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; j. 02/08/2016). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Veículo dos autores que foi apreendido por autoridade policial, sob suspeita de participação em crime, e posteriormente liberado. Proprietária que não ensejou a apreensão do bem, não sendo razoável que seja responsabilizada pelo pagamento da estadia. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação Cível 1008541-51.2019.8.26.0019; Relator Ruy Coppola; órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana, 2ª Vara Cível; data do julgamento: 30/03/2021). MANDADO DE SEGURANÇA. Liberação de veículo empregado em prática criminosa. Isenção do pagamento de taxas ou despesas. Possibilidade. Inteligência do artigo 271 do CTB. Remoção do veículo que não decorre de infração administrativa. Segurança concedida. (Mandado de Segurança criminal nº 2224544-39.2020.8.26.0000; Direito Criminal; Foro de Olímpia, Vara Criminal; data do julgamento: 16/10/2020).

Anoto, por oportuno, que para que liberação ocorra, as taxas e impostos relativos à propriedade do veículo (IPVA, licenciamento), devem estar devidamente quitados. Assim, diante da comprovação da propriedade, e não interessando mais o veículo à instrução criminal, nos termos do pleito de fls.186/188, DEFIRO a liberação do veículo FORD/KA GL IMAGE, ano fabricação/modelo 1999/2000, cor preta, Chassis 9BFBDZGDYB683293, placa CTB6J96, em favor de sua proprietária DAMIANA DE SOUZA SANTOS, RG 59.733.375-3 e CPF/MF 390.676.568/79, ou quem o represente. Oficie-se.

Anoto que a interessada é representada pelos mesmos advogados do réu, saindo intimada na pessoa deles de que, CASO EM 10 DIAS NÃO COMPROVE NOS AUTOS QUE RETIROU O VEÍCULO, SERÁ OFICIADO À AUTORIDADE POLICIAL PARA LEILÃO, SEM NOVAS INTIMAÇÕES. P.I. e C.

Atibaia, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA